实际施工人的建设工程价款优先受偿权实证研究

唐　倩

［摘　要］《合同法》第286条所确立的建设工程价款优先受偿权制度，对于矫正发包人与承包人的地位失衡，解决建筑实践中的工程款拖欠问题具有重要意义。而在转包、违法分包以及借用资质订立的建设工程施工合同中，实际施工人被拖欠工程款的问题更是严峻和复杂。实证研究表明，针对实际施工人确认建设工程价款优先受偿权，各地法院裁判结果不统一，说理不明确。从解释论的角度，无论是依文义解释、体系解释还是目的解释的方法，无效施工合同的承包人不应享有建设工程价款优先受偿权。但是，在有效施工合同中的总承包人、转包人或者出借资质人怠于行使建设工程价款优先受偿权时，为顺利实现因工程建设产生的合法债权，应当允许实际施工人可以提起代位权诉讼的方式主张建设工程价款优先受偿权。

［关键词］建设工程价款　优先受偿权 实际施工人 无效施工合同　代位权

［作　者］唐倩（1982—），女，重庆涪陵人，对外经济贸易大学法学院博士研究生，最高人民法院民事审判第一庭法官助理。主要研究方向：民商法学。

中图分类号：D923.6　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1674—0602（2019）04—0075—13

引言

由于建筑市场固定资产投资规模的过快增长，加上我国工程建设领域长期以来普遍存在的垫资承包方式，发包人拖欠工程款的现象日益突出。这一现象严重影响建筑施工企业的生产经营，制约企业发展；拖延工程建设的整体进度，限制行业发展；妨碍农民工取得工资报酬，引发社会问题。为切实保障承包人工程款债权的实现，我国《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付工程价款，经承包人催告后在合理期限内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将工程依法拍卖，承包人的工程价款可就折价或拍卖的价款优先受偿。通常认为，该条规定确立了我国的建设工程价款优先受偿权制度。

在建筑市场实践和司法审判实务的共同推动下，建设工程价款优先受偿权制度的各项要件不断得到细化和重构。但是，对于建筑市场中广泛存在的实际施工人这一主体，能否及如何行使建设工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

程价款优先受偿权的问题，仍然存在广泛争议。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《建设工程司法解释（一）》）中提出实际施工人的概念的主要目的，旨在保护实际施工人群体中广大农民工的工资报酬等合法权益，如果实际施工人不能顺利行使建设工程价款优先受偿权，无疑会为这类特殊群体的利益保护带来不利影响。要解决这一问题，必须从实证主义角度出发，明确我国在司法实践中实际施工人主张建设工程价款优先受偿权的具体运行情况，再结合相关法理进行分析，才能提出切实有效的完善建议。

一、实证数据之统计分析

（一）规范梳理

于2004年出台的《建设工程司法解释（一）》，一方面为国家清理拖欠工程款和农民工工资的产业政策提供司法保障，另一方面通过对诸多法律问题作出解释，规范了法律适用，统一了裁判尺度。〔1〕该解释的出台，对规范建筑市场主体行为，维护建设工程施工合同中各方当事人的合法权益，保障建设工程质量和施工安全起到了积极作用。为尽量维护合同效力，准确适用施工合同无效后的折价补偿规则，该解释第2条规定，施工合同无效但建设工程质量合格的，可以参照合同约定结算工程价款。而为妥善处理在违法分包、转包、借用资质订立的施工合同中，实际履行工程建设义务的主体的合法权益，《建设工程司法解释（一）》还提出了实际施工人的概念，赋予了违法分包和转包合同中的实际施工人享有对发包人的工程款诉权。〔2〕但是，该解释并未涉及《合同法》第286条规定的建设工程价款优先受偿权制度，对于实际施工人概念的内涵、外延及其权利义务内容也未作出明确，尤其是针对实际施工人是否享有建设工程价款优先受偿权这一具体问题没有进行规定，引发理论与实务界的长期争论。

在《建设工程司法解释（一）》出台之前，由于《合同法》第286条对建设工程价款优先受偿权的规定过于原则，最高人民法院于2002年制定了《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（以下简称《优先受偿权批复》）的司法解释，成为司法适用《合同法》第286条的重要依据。但是由于该批复主要是针对下级法院请示问题的批复，并非对建设工程价款优先受偿权制度的全面解释，除就建设工程价款优先受偿权对抵押权与消费者权益的优先效力、优先受偿的工程款范围以及优先受偿权的期限作出了相应规定外，并未对于优先受偿权的主体，也就是“承包人”的范围作出明确界定。〔3〕在建设工程项目的施工过程中，由于分包、转包以及借用资质订立施工合同的情形大量存在，施工合同中的主体异常复杂，大量的建设工程价款优先受偿权纠纷由不同主体提出，导致司法实践困难，“类案异判”问题进一步凸显。准确界定《合同法》第286条规定的承包人范围，对于司法机关规范法律适用、统一裁判尺度，真正实现建设工程价款优先受偿权的制度价值至关重要。

为此，部分地方法院在总结审判经验的基础上，制定相应的地方性司法文件针，对该问题提出适法意见。〔4〕经考察后发现，地方法院普遍认为，实际施工人虽属无效施工合同主体，但在一定条

〔1〕参见最高人民法院民事审判第一庭编著：《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》，人民法院出版社2004年11月版，第6页。

〔2〕参见《建设工程司法解释（一）》第26条第2款的规定。

〔3〕依照《优先受偿权批复》的规定：首先，建筑工程的承包人的优先受偿权优先于抵押权和其他债权，但是对已经交付全部或大部购房款的消费者，并不具有优先性；其次，建筑工程价款的范围仅包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；再次，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

件下，对其提出主张的建设工程价款优先受偿权，可以予以支持。具体而言，设置的条件通常包括两个方面：一是实际施工人履行了施工合同约定的施工义务，且已完工程的质量能够达到合格标准；二是施工合同的总承包人或转包人存在不主张或者怠于向发包人主张建设工程价款优先受偿权的行为，对实际施工人的工程款权益造成损害。此类地方性司法文件为当地法官统一裁判规则创造了条件，取得了良好的效果，但也存在一定的缺陷：首先，上述司法性文件仅提出对违法分包或转包中的实际施工人提供保护，但未涉及借用资质订立施工合同中的实际施工人，规范内容并不全面；其次，依照《立法法》及相关法律规定，地方性司法文件由地方司法机关制定，既不同于由地方人大及常委会制定的地方性法规，也不同于由行政主管机关制定的部门规章，并不具有法律效力，仅在本辖区内的司法活动中具有一定的参考和指导价值，不具有强制性，不能在法律文书中援引。〔5〕

为加强对建设工程施工合同纠纷案件的裁判指引工作，2011 年召开的全国民事审判工作会议明确提出，对由违法分包、转包等无效施工合同中的实际施工人提出建设工程价款优先受偿权的主张，不予支持。〔6〕在此司法理念的指导下，最高人民法院于 2018 年发布《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（以下简称《建设工程司法解释（二）》）的第 17 条规定，将建设工程价款优先受偿权的主体明确规定为与发包人订立建设工程施工合同的承包人。依照司法解释制定机构对该条规定的进一步解读，根据合同相对性原理，实际施工人不是发包人的债权人，在对实际施工人的诉讼主体地位和实体权利义务作出认定时，应严格依照《建设工程司法解释（一）》第 26 条的相关规定，不能扩大适用范围和条件。由此，依法享有建设工程价款优先受偿权的主体必须与发包人存在直接的施工合同关系，实际施工人因与发包人不具有直接合同关系，被排除在建设工程价款优先受偿权的主体之外。〔7〕从反面论证的角度，建设工程价款优先受偿权是否绝对不能由实际施工人行使，仍有讨论空间。

（二）司法现状

司法实践中，实际施工人以诉讼方式主张建设工程价款优先受偿权纠纷的案件大量存在，通常表现为两种方式：一是在以建设工程施工合同纠纷为案由的案件审理过程中，实际施工人在依据《建设工程司法解释（一）》第二十六条第二款的规定，向发包人主张欠付工程款的同时，一并提出确认建设工程价款优先受偿权主张；另一种则是以 2011 年 2 月《民事案件案由规定》作出修正后，增加规定的建设工程价款优先受偿权纠纷为案由，由实际施工人直接向人民法院提起建设工程价款优先受偿权确认之诉。〔8〕不同的主张方式，对举证责任的分配、举证程度的要求存在较大差别，对于实际工人提出的主张是否能够得到支持存在较大影响。

总体而言，由于《建设工程司法解释（一）》并未对实际施工人是否享有建设工程价款优先受偿权作出明确规定，人民法院在审查由实际施工人提出工程价款优先受偿权的主张时，存在不同裁判

〔4〕参见《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》（2018）第 16 条、《河北省高级人民法院关于印发〈建设工程施工合同案件审理指南〉的通知》（2018）第 33 条、《浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（2012）第 22 条、《广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见》（2011）第 15 条以及《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见》（2009）第 18 条。

〔5〕参见荣振华：《地方法院发布“司法解释性质文件”的生存样态及可能走向》，载《甘肃政法学院学报》2018 年第 4 期，第 90 页。

〔6〕参见《2011 年全国民事审判工作会议纪要》第 29 条。

〔7〕参见最高人民法院民事审判第一庭编著：《最高人民法院建设工程施工合同司法解释（二）》理解与适用》，人民法院出版社 2019 年版，第 370 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

思路。有法院认为，实际施工人作为最终完成工程施工的主体，对工程建设的实际投入应当受到建设工程价款优先受偿权的保护，否则违背建设工程价款优先受偿权制度的功能，违反公平原则，与《建设工程司法解释（一）》关于参照合同约定结算工程价款的规定亦不相符。例如在“齐齐哈尔奇兴房地产开发有限公司与王庆伏建设工程施工合同纠纷案”中，人民法院认为，王庆伏、施泽龙以挂靠的方式订立建设工程分包合同，具有实际施工人的身份，但因其对工程支付的部分材料款、人工费已经物化进入建设工程中，转化为工程价款，由此主张的建设工程价款优先受偿权符合《优先受偿权批复》的规定，应当得到支持。〔9〕但是，也有法院认为，建设工程价款优先受偿权以存在合法有效的施工合同为基础，实际施工人作为违法合同主体，不具有享有建设工程价款优先受偿权的合法性事由。譬如在“四川永同岩土工程有限公司与四川水电建设工程（集团）有限责任公司、苍溪县江河水电开发有限公司建设工程施工合同纠纷案”中，人民法院认为，工程价款优先受偿权的目的是在合同有效的基础上保护承包人的利益，分包合同无效的情形下，实际施工人不具备法律意义上享有工程价款优先受偿权的资格，因而驳回了其诉讼请求。〔10〕排除因地域因素而产生司法裁判规则不统一的现象，在“广西通桂建设工程有限公司与柳州市市政工程集团有限公司、防城港天寓房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案”中，一审法院以建设工程价款优先受偿权保护的对象须是因合法有效的施工合同所产生的债权，否定了无效合同中的实际施工人享有建设工程价款优先受偿权；而二审法院则认为，施工合同无效，并不必然导致优先受偿权的丧失，一、二审法院关于实际施工人是否享有建设工程价款优先受偿权的看法并不一致。〔11〕

即便是在2019年2月1日《建设工程司法解释（二）》施行以后，裁判规则不统一的状况也并未得到有效缓解。例如，在“倪海生与陈伟、徐州腾美建设工程有限公司等建设工程施工合同纠纷案”中，对于倪海生请求判令对其施工的工程拍卖或变卖后的价款享有优先受偿权的诉请，人民法院以违反《建设工程司法解释（二）》第17条的规定为由，予以驳回。〔12〕而在“班兆刚与广西诚君商贸优先责任公司建设工程施工合同纠纷案”中，人民法院一方面确认了班兆刚的实际施工人身份，另一方面仍认定班兆刚可以依照《合同法》第286条以及《建设工程司法解释（二）》第22条的规定，对涉案工程项目享有优先受偿权。〔13〕在“黄显林、湖北荆门团结科技产业园投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷案”中，二审法院甚至认为，黄显林作为挂靠施工合同中的实际施工人，与发包人团结公司就案涉工程成立了事实上的施工合同关系，黄显林实为与发包人订立施工合同的承包人，符合《建设工程司法解释（二）》第17条的规定，可以作为工程价款优先受偿权的主体。〔14〕由此可知，对于《建设工程司法解释（二）》第17条规定的具体适用，不同法院仍然存在不同理解。

（三）规则研判

为全面考察人民法院在实际施工人主张建设工程价款优先受偿权纠纷中的裁判规则，本文针对实际施工人主张建设工程价款优先受偿权的不同方式，选取不同的数据样本进行具体分析。数据样

〔8〕参见最高人民法院民事案件案由规定课题组编著：《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用》，人民法院出版社2011年版，第168页。

〔9〕参见黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院（2015）齐民一终字第179号民事判决书。

〔10〕参见四川省苍溪县人民法院（2017）川08民终1210号民事判决书。

〔11〕参见广西壮族自治区防城港市中级人民法院（2014）防市民一终字第537号民事判决书。

〔12〕参见江苏省徐州市鼓楼区人民法院(2017)苏0302民初3778号民事判决书。

〔13〕参见广西壮族自治区平果县人民法院(2018)桂1023民初1354号民事判决书。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本 1 收集了中国裁判文书网中，实际施工人起诉发包人主张工程款债权，同时主张工程价款优先受偿权的 186 个案例。该数据样本具有两个特点：一是实际施工人依照《建设工程司法解释（一）》第 26 条第 2 款的规定，起诉发包人请求支付欠付工程款，同时提出行使建设工程价款优先受偿权的主张；二是发包人是否欠付工程款以及工程价款的数额及范围须经人民法院作出实体审查。经统计，实际施工人以该种方式主张建设工程价款优先受偿权，被法院驳回的机率非常高，样本收集到的 186 个相关案例中，被法院驳回诉讼请求的有 151 例，获得支持仅有 35 例，占比不足样本数据的 20%。驳回的理由主要集中在由实际施工人主张的建设工程价款优先受偿权，不符合《合同法》《优先受偿权批复》《建设工程司法解释（二）》关于建设工程价款优先受偿权行使要件的规定。具体而言，或者是人民法院经审查后认定，发包人并不存在欠付工程款的情形。由于建设工程价款优先受偿权具有附从性，明确工程款主债权是确认工程价款优先受偿权的前提。发包人欠付工程款范围不明确的情况下，人民法院无法对建设工程价款优先受偿权作出单独的确认。或者是依工程性质，不适宜进行折价、拍卖，不符合建设工程价款优先受偿权的实现程序和方式。〔15〕例如在“海口益民惠通建设有限公司、海口市菜篮子投资发展有限公司等建设工程施工合同纠纷案”中，因涉案工程是民生工程，具有公益性质，涉及公共利益，按照性质属于不宜折价、拍卖的工程，故对关于建设工程优先受偿权的主张，人民法院未予支持。〔16〕又或者是实际施工人所依据的债权不属于优先受偿权保护的“工程价款”范畴。依照建设工程价款优先受偿权制度的立法目的，并非承包人能够取得的全部合同利益均能通过建设工程价款优先受偿权得以实现，应严格限定在承包人所应支付的工作人员报酬和材料款等实际支付的费用之内；并且，承包人行使优先受偿权所及的对象应仅限于自己承建的工程。还可能因超出法定期限，导致建设工程价款优先受偿权的丧失。《优先受偿权批复》将承包人行使建设工程价款的期限规定为自建设工程竣工之日或者施工合同约定的竣工之日其起六个月内，目的是为了敦促承包人尽快行使优先受偿权，否则会导致相应的法律关系长期处于不稳定状态，妨碍交易安全，不利于维护抵押权人等第三人的合法权益。《建设工程司法解释（二）》在此基础上，规定承包人应当自发包人应当给付建设工程价款之日起六个月内行使建设工程价款优先受偿权，对批复确立的起算时间作出修正，一来更加能够体现建设工程价款优先受偿权担保工程款债权实现的附从性，二来也更加具有可操作性，因为从建筑市场实践来看，无论是实际竣工时间还是约定竣工时间的确定都是非常困难的。

数据样本 2 同样来源于中国裁判文书网，收集到实际施工人直接提起建设工程价款优先受偿权确认之诉的 26 个相关案例。较样本 1，该数据样本具有以下特点：一是业经生效的判决书或者调解书确认发包人欠付工程价款的范围或具体数额；二是实际施工人直接提起建设工程价款优先受偿权确认之诉 ；三是实际施工人主张建设工程价款优先受偿权的对象不仅包括发包人，还包括违法分包人或者转包人。〔17〕经考察，实际施工人以该种方式主张建设工程价款优先受偿权，获得支持的比例明显要高，在样本收集的 26 个案例中，仅有 8 例被法院驳回。驳回的理由多以实际施工人的主张超过法定期限（例如在朱祖兴与无锡锡工公司、项永甫与浙江梅荣公司、尚仕清与宁国福友公司的建

〔14〕参见湖北省荆门市中级人民法院（2019）鄂 08 民终 72 号民事判决书。

〔15〕最高人民法院制定《建设工程司法解释（二）》的过程中，曾经在面向社会的征求意见稿中对不宜折价、拍卖的建设工程作出了列举式规定，具体包括未取得或违反工程规划许可手续、质量验收不合格、事业单位、社会团体以公益目的建设的公益设施、国家机关用房或军事建筑以及无法独立存在或者分割后影响主体建筑功能的附属工程等类型的工程。由于司法解释仅关注审判实践中最具争议、最亟待解决的问题，最终出台的司法解释对未保留此条规定。

〔16〕参见海南省高级人民法院（2018）琼民初 46 号民事判决书。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设工程价款优先受偿权纠纷中，人民法院均以实际施工人提出建设工程价款优先受偿权的主张已经超出《优先受偿权批复》第四条所规定的六个月的行使期限，驳回了实际施工人的诉讼请求）〔18〕或者其所依据的债权不属于“工程价款”范畴为主（例如在广东开平集团与佛山富地公司施工合同纠纷一案中，因认定钢材款不属于建设工程价款优先受偿权所保护的工程款范畴，人民法院驳回了实际施工人的相应请求）〔19〕。这主要是因为，在此方式中，实际施工人的工程款债权已由生效法律文书固定，人民法院无须再就发包人是否欠付工程款以及欠付工程款的数额作出预判。

综合以上规则分析，人民法院在审查实际施工人提出的建设工程价款优先受偿权时，仍然存在三方面的法律问题：一是欠缺对实际施工人概念的准确界定，实际施工人负有的权利义务及其来源尚不明晰；二是缺乏合同效力对工程价款优先受偿权的基础性认识，该制度的法定性对合同效力的前提要求，往往让位于保护弱势群体的司法政策；三是为完善保护实际施工人权益，应积极寻求实际施工人突破合同相对性行使建设工程价款优先受偿权的法理依据。

二、适用疑难之法理论证

（一）实际施工人的权利义务来源

严格来讲，实际施工人并非一个完全的法律概念，《建设工程司法解释（一）》出台之前，《合同法》《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规均未使用过“实际施工人”来表述施工合同承包人的概念。《建设工程司法解释（一）》提出实际施工人的概念，却未对其内涵和外延作出准确界定，成为人民法院适用建设工程价款优先受偿权制度时产生疑难的主要原因之一，但此次出台的《建设工程司法解释（二）》，对此问题仍未作出明确规定。由于《建设工程司法解释（一）》的作出机构对实际施工人的解读并未凸显其投入人工、资金、材料成本等的物化属性为此，诸多地方法院尝试对实际施工人的概念作出重新定义，〔20〕普遍认为《建设工程司法解释（一）》使用“实际施工人”的概念，意在表达无效施工合同中实际完成工程建设的施工主体，但并非所有无效施工合同的主体均可被认定为实际施工人。〔21〕

笔者认为，由于《建设工程司法解释（一）》第1条对无效建设工程施工合同作出规定时，对因未取得资质、超越资质等违反资质管理规定而导致合同无效的施工合同承包人，该条第1项采用了“承包人”的表述；而对因借用资质承揽工程并进行施工的无效合同当事人，该条第2项单独采用了“实际施工人”的表述。可以看出，这一规定方式的目的是为了与借用资质行为中通过出借资质与发包人订立施工合同的承包人进行区别。通过对《建设工程司法解释（一）》中规定实际施工人的全部条

〔17〕 例如在陆洪、管明等诉江苏中瑞路桥建设有限公司建设工程价款优先受偿权纠纷系列案件中，原告陆洪、管明等人为涉案工程的实际施工人，被告江苏中瑞路桥建设有限公司为涉案工程的承包人，陆洪等人起诉请求确认其对欠付工程款享有工程价款优先受偿权，法院判决支持陆洪、管明等实际施工人对被告结算的工程款享有优先受偿权。参见湖北省十堰市郧阳区人民法院（2016）鄂0321民初1322、1323、1324、1326、1327、1328号民事判决书。

〔18〕 参见江苏省无锡市锡山区人民法院（2017）苏0205民初3900号民事判决书、安徽省宣城市中级人民法院（2015）宣中民二终字00089号民事判决书以及浙江省绍兴市中级人民法院（2012）浙绍民终字第443号民事判决书。

〔19〕 参见广东省佛山市禅城区人民法院（2016）粤0604民初13306号民事判决书。

〔20〕 参见肖峰、严慧勇、徐宽宝：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》解读与探索》，载《法律适用》2019年第7期，第103页。

〔21〕 参见《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》第18条、《河北省高级人民法院建设工程施工合同案件审理指南》第29条。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

款作出综合分析，所谓的“实际”施工人，均须以“名义”施工人的存在为前提，否则该解释第 26 条第 2 款关于实际施工人对发包人诉权的规定将无适用余地。因此，基于《建设工程司法解释（一）》对无效施工合同的类型化，将借用资质订立的施工合同中的施工人、转包合同中的施工人以及违法分包合同中的施工人三类主体认定为实际施工人，更加符合法律规范内部统一性的要求。

由此，违法分包、转包和借用资质的施工合同中，实际施工人与发包人之间并不存在直接、有效的合同关系。但是，从承包人与实际施工人之间法律关系的形成角度看，双方意思表示的内容以及合意的目的，均是为了实现将承包人从发包人处承揽的建设工程的施工义务，全部或者部分交由实际施工人完成；实际施工人的施工行为所指向的对象为建设工程，与承包人和发包人订立的施工合同的标的物一致。尽管这一从双方之间法律关系的履行角度看，实际施工人的施工行为以承包人的施工合同义务为基础，实际施工人对工程的实际投资与建设，在事实上具有履行施工合同中承包人的合同义务的性质。由此，二者具有相当程度的关联性，实际施工人对于该建设工程享有的权利义务，是由承包人在其与发包人之间的施工合同中享有的权利义务转化、承继而来。

较为特殊的是，由于《建设工程司法解释（一）》第 26 条第 2 款仅对违法分包和转包合同中的实际施工人的权益保护问题作出了明确规定，但并未涉及借用资质订立施工合同中的实际施工人的权益保护问题，该条规定并不能直接适用于借用资质订立施工合同中的实际施工人。笔者认为，依照《民法总则》第 146 条的规定，借用资质订立施工合同的行为，属于通谋虚伪行为。因出借资质的承包人欠缺与发包人订立施工合同的真实意思，双方并不存在实质上的法律关系；而是由借用资质的实际施工人与发包人在订立和履行施工合同的过程中，形成了一系列事实上的法律关系，产生了债法上的请求权。[22] 据此，借用资质的实际施工人仍然可以依据《合同法》第 58 条的规定，直接向发包人主张。

概括而言，实际施工人因对工程进行建设而产生的事实上的权利义务，不可能超出借用资质人、总承包人或转包人依据施工合同享有的权利义务的范围。

（二）施工合同效力与建设工程价款优先受偿权

就承包人与发包人订立的施工合同，确因违反法律的强制性规定等原因而被人民法院认定为无效，该无效合同的承包人是否仍可主张建设工程价款优先受偿权的问题，司法机关仍存在不同思路：部分地方法院作出规定，在建设工程施工合同无效的情形下，承包人向发包人主张建设工程价款优先受偿权的，人民法院不应予以支持。[23] 但也有地方法院对此问题作出相反的规定，认为在建设工程质量合格的前提下，即便施工合同无效，承包人提出就建设工程优先受偿的主张，仍应得到支持。[24]

支持无效合同承包人享有工程价款优先受偿权的观点首先认为，因我国建筑立法对施工企业资质和招投标程序的严格规制，现实中有大量的施工合同被认定为无效，如果将优先受偿权的行使条件限定为有效合同，将会导致众多承包人尤其是实际施工人的工程款债权失去有效保护，建设工程价款优先受偿权的制度功能也会大打折扣。[25] 其次，赞成无效施工合同承包人依然享有建设工程价款优先受偿权的观点还认为，因工程价款优先受偿权制度的设立是以保护承包人已经物化到建筑物中的劳动和建筑材料为目的，依照《建设工程司法解释（一）》第 2 条的规定，施工合同无效，但工程经过竣工验收合格的，承包人仍可请求参照合同约定结算工程款。建设工程价款优先受偿权的权利基础

〔22〕参见朱树英：《工程合同实务问答》，法律出版社 2007 年版，第 59 页。

〔23〕参见《广东省高级人民法院关于在审判工作中如何适用〈合同法〉第 286 条的指导意见》第 7 条。

〔24〕参见《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见》第 17 条。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来源于工程款债权，既然工程款债务仍需清偿，建设工程价款优先受偿权理应得到支持。〔26〕最后，尽管有学者认为，承包人的利润作为商业利益，对其适用建设工程价款优先受偿权不符合该制度的价值取向，〔27〕但是《建设工程司法解释（二）》第21条仍然作出规定，将原《优先受偿权批复》所规定的承包人就建设工程能够优先受偿的款项范围，扩张至由国务院有关行政主管部门确定的建设工程价款范围，不仅包括直接支付的人工费、材料费，还包括利润、规费、税金等费用，与无效合同的承包人参照合同约定结算的工程价款涵盖的范围一致。无效合同承包人主张建设工程价款优先受偿权的障碍被进一步消除。

笔者认为，建设工程价款优先受偿权以承、发包双方之间存在合法有效的施工合同为前提，无效施工合同的承包人不应享有建设工程价款优先受偿权。首先，单纯从理论上进行的分析并不能代替对法律规范本身的考察，应将《合同法》第286条的规范构成作为我们立论和论证的基础。依照解释论的观点，文义解释是全部法律解释出发点。〔28〕进行文义解释要求在尊重法律文本的基础上，遵循同一解释规则，即要求同一概念在同一法律部门内、甚至不同法律部门内，都应当尽可能保持含义的一致，以实现法律的安定性、客观性和可预测性。〔29〕而就文义解释的方法来讲，不同语词的使用在很大程度上意味着涵义上的巨大差别。《合同法》第286条规定承包人主张建设工程价款优先受偿权的重要前提，是发包人未“按照约定”支付工程价款，通过对我国《合同法》进行统计可知，《合同法》全文共有65条70处采用了“按照约定”的概念。其中，总则部分的条文具体为《合同法》第60条、第九91条、第121条，分别位于第四章“合同的履行”、第六章“合同的权利义务终止”以及第七章“违约责任”中。从概念的归属可以看出，“按照约定”的适用都是以合同的有效为基础。同样，在《合同法》的分则部分，“按照约定”概念也都适用于合同有效的相关规范中。相应地，依照《建设工程司法解释（一）》第2条的规定，无效合同中的承包人在工程经竣工验收之后，可以参照合同约定结算工程价款。对于该条中“参照”的概念，汉语词典中确定的基本语义为“参考并仿照”，与按照包含的“依照、根据”的语义存在明显差别。〔30〕《合同法》仅在第12条1处使用了“参照”这一概念，具体内容是当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同，从侧面反映了参照的对象通常不具有法律强制力，与规范内容的效力无关。

其次，依照《合同法》第58条确立的规则，合同被认定为无效后，首先应将双方当事人之间的法律关系恢复到合同订立之前的状态，在不能实现原物返还或者没有必要返还原物的情形下，适用折价补偿的方式。由于建设工程施工合同的特殊性，无效合同承包人因工程建设投入的劳动力和建筑材料已经物化到建筑中，建设工程对于承包人来讲价值不大且不易变现，不宜采取原物返还的方式。由此，《建设工程司法解释（一）》第二条规定无效合同承包人可以请求参照合同约定结算工程价款，实质上是对其在履行无效施工合同过程中，实际投入的人员和物资等作出的补偿，是在将无效合同的处理原则和当事人的利益平衡进行综合考量之后作出立法选择。〔31〕施工合同无效后，双方的合同已非当事人请求折价补偿的基础，能够参照结算的合同范围仅包括合同中有关工程款计价方

〔25〕参见陈东强：《建设工程价款优先受偿权的行使与规制》，载《山东法官培训学院学报》2018年第5期，第45页。
〔26〕参见李后龙、潘军锋：《建设工程价款优先受偿权审判疑难问题研究》，载《法律适用》2016年第10期，第67页。
〔27〕参见王旭光：《建筑工程优先受偿权制度研究——〈合同法〉第286条的理论与实务》，人民法院出版社2010年版，第171页。
〔28〕参见[德]魏德士著：《法理学》，丁晓春、吴越译，法律出版社2005年版，第319页。
〔29〕参见王利明著：《法律解释学导论——以民法为视角》，法律出版社2009年版，第237页。
〔30〕中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》，商务印书馆2005年版，第129页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法和计价标准的约定，也已为司法实践所认可。〔32〕无效施工合同中承包人主张的工程价款，与《合同法》第 286 条规定按照合同约定应当支付的工程价款，即便都采用了“工程价款”这一概念来表述，在性质上并不具有同一性，支持无效合同承包人享有建设工程价款优先受偿权的这一理由并不成立。

再次，合同无效体现了国家对法律行为最为强烈的否定性评价，〔33〕无效施工合同的承包人主张建设工程价款优先受偿权缺少合法性。同时，有效施工合同中的承包人在享有建设工程价款优先受偿权时，还以承担相应的后合同义务和附随义务为条件，如无效施工合同中的承包人与其享有同样的权利，却不必承担相同的义务，无疑对守法的有效合同当事人极不公平，无异于鼓励当事人的不法行为，不利于建筑市场的健康发展。有观点认为，应当以导致施工合同无效的过错大小作为区分标准，来决定是否赋予以及如何配置优先权。〔34〕笔者认为，虽然依照我国合同责任二元论的观点，我国合同法并不排斥过错责任的归责原则。〔35〕但是，工程价款优先受偿权作为施工合同承包人的法定权益，由人民法院依过错程度加以认定缺少明确法律依据。

最后，关于建设工程价款优先受偿权具有的保护处于弱势地位的承包人的立法目的问题。笔者认为，以工程价款中包含农民工工资，而农民工的生存权益高于经营权益来解释建设工程价款优先受偿权的立法目的，显然是片面的。〔36〕建设工程价款优先受偿权中体现的对承包人应支付的工人工资和工程建设的垫付资金等给与优先偿付的机制并非我国独有，众多国家在其民事法律或判例中对建设工程价款的优先受偿机制作出相应的规定。但我们也应当看到，建设工程价款优先受偿权并非适用于平衡发包人与承包人之间的关系，而主要是适用于平衡承包人与发包人的其他债权人之间的关系，在工程需要通过折价或者拍卖用以偿还债务的情形下，债权的优先性与发包人并无直接关联。作为法律规定对施工合同承包人作出的特殊保护措施，建设工程价款优先受偿权是以牺牲其他债权的优先性，降低担保物权的可预测性为代价的制度。为减少优先权制度的负面影响，部分国家对建设工程价款优先受偿权的规范方式呈现出由法定向意定，特别优先向一般优先的变化趋势。随着建筑行业的发展，建设工程价款优先受偿权适用困难的现象会愈发严重，适用的范围会愈发狭窄，各国都在积极寻求其他途径，例如以修改工程担保制度的方式来实现对建设工程价款债权人的保护。〔37〕我国对于无效施工合同承包人的折价补偿请求权，也在立法、行政机关共同参与的多元化保护机制的不断尝试中持续完善与发展，不能享有建设工程价款优先受偿权，并不意味着其合法权益无法得到有效保护。

（三）实际施工人代位行使建设工程价款优先受偿权的可行性分析

在施工合同有效的前提下，承包人可以通过行使建设工程价款优先受偿权，使其工程款债权得到优先实现。而在违法分包、转包和借用资质订立的施工合同中，存在发包人与承包人、承包人与

〔31〕参见冯小光：《〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉的理解与适用》，载《建筑经济》2005 年第 1 期，第 8 页。

〔32〕在“黄国盛、林心勇与江西通威公路建设集团有限公司等建设工程分包合同纠纷一案”中，最高人民法院即认为，《建设工程司法解释（一）》第 2 条规定的“参照合同约定支付工程价款”，主要是指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定，并不包括合同对支付条件的约定。

〔33〕参见谢鸿飞：《论法律行为生效的“适法规范”——公法对法律行为效力的影响及其限度》，载《中国社会科学》2007 年第 6 期，第 124 页。

〔34〕参见宿辉：《建设工程价款优先受偿权论争》，载《重庆社会科学》2017 年第 9 期，第 79 页。

〔35〕参见杨立新：《论我国合同责任的规则原则》，载《河南公安高等专科学校学报》2003 年第 2 期，第 6 页。

〔36〕参见王建东：《评〈合同法〉第 286 条司法适用疑难问题探讨》，载《中国法学》2003 年第 2 期，第 66 页。

〔37〕参见顾长河、张婧：《比较法视野下的建筑工程优先权的发展趋势及其完善》，载《岭南学刊》2011 年第 5 期，第 69 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实际施工人、实际施工人与发包人的多重法律关系，对各法律关系中的行为效力应当进行具体分析，以确定建设工程价款优先受偿权的适用。

首先，依照《建设工程司法解释（一）》第 4 条的规定，在转包和违法分包的情形下，总承包人、分包人与实际施工人之间的行为当为无效，但总承包人、转包人与发包人之间订立的施工合同的效力，不受违法分包和转包行为无效的影响，不能由承包人与实际施工人之间的行为无效反推承包人与发包人之间的合同无效。其次，在实际施工人借用资质订立的施工合同的情形下，认定各方行为的效力较为复杂。尽管《建设工程司法解释（一）》已经明确规定没有资质的实际施工人借用资质订立的施工合同无效，但在司法实践中，对于“没有资质”的这一规定往往被扩大理解为实际施工人在订立合同时，存在借用资质的行为，对于其本身的资质状况在所不问。通过对我国建筑企业资质管理规定的强制性作出分析，笔者认为，在施工企业具备相应资质，仅违反资质管理规定存在借用资质订立施工合同的行为，或是施工企业暂时存在资质缺陷，但在规定期限内能够进行补正的情形下，并不会对施工安全和工程质量造成威胁，不违反资质管理规定的立法目的，实际施工人借用资质订立的施工合同并非必然无效。〔38〕

针对借用资质的实际施工人，《民法总则》第 146 条的规定已经赋予其直接向发包人主张建设工程价款优先受偿权的权利。但是对于违法分包和转包合同中的实际施工人来讲，由于合同法奉行的相对性原则，合同的拘束力原则上仅仅及于合同当事人各方，第三人既不享有合同项下的权利，也不承担合同项下的义务，此类实际施工人应如何主张工程价款优先受偿权仍存有疑问，值得探讨。

由于客观需要，立法政策在一定情况下允许突破合同的相对性原则，使某些合同对特定的第三人发生法律效力，《合同法》第 73 条规定债权人的代位权制度，即是合同对第三人有效的表现之一。〔39〕代位权制度也为《建设工程司法解释（一）》第 26 条第 2 款关于违法分包和转包合同中的实际施工人直接向发包人主张工程欠款的规定，提供了充分的法理依据。《建设工程司法解释（二）》第 25 条明确规定，在违法分包或者转包人怠于向发包人形式到期债权时，实际施工人可以向发包人提起代位权诉讼。笔者认为，违法分包和转包合同中的实际施工人也可以向发包人提起代位权诉讼的方式，主张享有建设工程价款优先受偿权。在此制度下，实际施工人就建设工程优先受偿的权益将得到延伸。

为保障债权人正确行使代位权，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释》（以下简称《合同法司法解释（一）》）第 11 条规定，债权人向第三人提起的代位权诉讼，必须符合三项的条件：一是债权人的债权合法，且已到期。二是债权的性质非专属于债务人自身。三是因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成了损害的后果。实际施工人虽为违法施工行为的主体，但并不意味着其享有的债权非法，实际施工人在工程建设中实际投入的人工和物资，因合同无效产生了折价补偿的请求权，属于合法债权。关于建设工程价款优先受偿权是否属于专属于承包人的权利，不能由他人代位行使的问题，笔者认为，建设工程价款优先受偿权以保障承包人的工程款债权为目的，无疑是基于承包人身份而享有的特殊权益，但是依照《合同法司法解释（一）》第 12 条的规定，建设工程价款优先受偿权涵盖的债权内容并不属于该条规定的基于人身权或者人身依附关系而产生的给付请求权范围。《优先受偿权批复》以及《建设工程司法解释（二）》虽规定工程款债权的范围包括承包人为建设工程应当支付的员工报酬等费用，但相对于实际施工人，这类债权并不具有专属性，

〔38〕参见唐倩：《挂靠施工合同的效力分析》，载《法律适用》2019 年第 5 期，第 88 页。

〔39〕参见崔建远著：《合同法总论（中）》，中国人民大学出版社 2008 年 6 月版，第 264 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而是表现为实际施工人在进行工程建设中的成本，且在转包、违法分包和借用资质订立的施工合同中，上述费用已经由实际施工人支出。

另外，因建设工程价款优先受偿权对一般抵押权的优先效力，在很大程度上体现出物权的属性，而依照《合同法司法解释（一）》第 13 条对代位权制度的具体规定，代位权制度的适用范围被限定在具有金钱给付内容的债权范畴，建设工程价款优先受偿权似不能成为代位权的客体。的确，由于《合同法》第 286 条在规定建设工程价款优先受偿权制度时，并未明确该权利的具体性质，引发了学界的长期争论，至今尚无定论。目前较为流行的“留置权说”“法定抵押权说”〔40〕以及“优先权说”〔41〕在对建设工程价款优先受偿权的概念和性质界定方面存在区别，但在对其作出的立法定位中可知，上述学说均认可建设工程价款优先受偿权的物权属性。而从《优先受偿权批复》的内容看，司法机关采用了优先权的性质。〔42〕

但笔者认为，这并不妨碍建设工程价款优先受偿权成为代位权制度的客体。首先，从法律体系的角度，建设工程价款具有物权属性，但其亦绝非完全意义上的物权，建设工程价款优先受偿权制度和代位权制度同属于我国《合同法》上所规定的制度，在同一部门法律关系中适用不应存有障碍。其次，我国现行法律对于代位权客体的规定过于狭窄。传统法律观念认为，代位权并非专属于合同法上的概念，与我国《合同法》规定的债权人代位权制度相对应的还有民法上的代位权制度，其权利客体包括物上请求权、形成权等，甚至包括其他非权利行使的保全行为。〔43〕依比较法的观点，诸多国家或地区如日本、法国以及我国台湾地区，可以行使代位权的权利内容非常广泛，其民法中对于代位权客体类型的规定，比我国现行规定要宽泛得多。在日本民法中，除专属于债务人自身的权利以外，都可以由债权人代位行使。〔44〕法国民法甚至规定诉权也可以成为代位权的客体。〔45〕为更好地发挥代位权制度的作用，应当采目的性扩张的解释方法，将我国代位权制度的客体扩展到对物权及物权请求权。再次，有学者提出，物权原则上不能成为代位权的客体，是因为债务人享有的物权大都通过登记产生，即使债务人怠于主张，物权也不会消灭，不会影响债权人的权益。〔46〕笔者认为，即使是建立在这一理由上，工程价款优先受偿权也应当能够代位行使。因为《合同法》在规定建设工程价款优先受偿权制度时，并未对其对其是否登记与如何登记进行规范，未经登记即可成立并生效甚至被众多学者认为是建设工程价款优先受偿权的重要特征之一，域外法律对优先权或者法定抵押权是否必须登记也各有不同的规定。〔47〕而依照《优先受偿权批复》第 4 条的规定，建设工程价款优先受偿权的行使期限为六个月，承包人如怠于行使会导致建设工程价款优先受偿的权利消灭，直接影响实际施工人的债权的实现。

三、司法适用之规范建议

〔40〕参见梁慧星：《合同法第二百八十六条的权利性质及其适用》，载《山西大学学报》2001 年第 3 期，第 5 页。

〔41〕参见梅夏英：《不动产优先权与法定抵押权的立法选择》，载《法律适用》2005 年第 2 期，第 53 页。

〔42〕参见汪治平：《建设工程价款优先受偿权的若干问题》，载《人民司法》2002 年第 8 期，第 5 页。

〔43〕参见龙艳芳、陈航：《浅谈债权人的代位权——市场经济下的债权人代位权的思考》，载《经济与法》2015 年第 6 期，第 170 页。

〔44〕参见《日本民法典》，王书江译，中国法制出版社 2000 年版，第 80 页。

〔45〕参见《拿破仑法典》，李浩培译，商务印书馆 1979 年版，第 155 页。

〔46〕参见王利明：《论代位权的行使条件》，载《法学论坛》2001 年第 1 期，第 37 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（一）立法定位与具体规范

《合同法》第286条确立的建设工程价款优先受偿权的制度在我国长期缺乏体系化的理论和立法支持。鉴于建设工程价款优先受偿权基于《合同法》的直接规定而产生，属于与社会价值观念和国家政策密切相关的特殊债权担保方式，无论将其归属至法定抵押权或是优先权的范畴，其优先于意定抵押权的效力是明确的，于实践并无影响。并且，参考域外立法例，德国、日本以及我国台湾地区都存在与我国建设工程价款优先受偿权相类似的法律制度，台湾地区“民法”称之为“承揽人之法定抵押权”，《日本民法典》称之为“不动产保存、工事之先取特权”，皆是由于存在不同的法律传统以及不同的立法政策而致。德国、我国台湾地区因在民法典中废止了系统的优先权制度，而产生法定抵押权这一概念，在本质上属于优先权制度的另一名称。〔48〕我国在引入优先权制度过程中，对其概念和性质的界定，毫无疑问会影响其立法定位。在制定《物权法》时，有学者提出在《物权法》中对优先权进行规范，〔49〕但是由于对其物权性质的认定未获统一，优先权制度未被纳入《物权法》调整范围。如今，我国正处于《民法典》的编纂时期，又有学者提出应当把握这一契机，对优先权制度进行规范，〔50〕然而反对的声音也一直存在。〔51〕对优先权制度的立法规范，必定任重而道远。

在现有法律、司法解释对实际施工人如何行使建设工程价款优先受偿权并未作出明确规定，导致司法机关适法困难的情况下，建议最高人民法院可在《建设工程司法解释（二）》对建设工程价款受偿权主体作出规定的基础上，就实际施工人应如何行使建设工程价款优先受偿权作出进一步解释。具体而言，考虑到无论是在《建设工程司法解释（一）》，还是《建设工程司法解释（二）》中，对借用资质的实际施工人的权益保护均未涉及，司法机关在审理此类实际施工人主张的建设工程价款优先受偿权纠纷案件时，仅需对施工合同的效力作出审查，能够认定借用资质订立的施工合同有效的，借用资质的实际施工人可以直接向发包人主张建设工程价款优先受偿权。对违法分包和转包合同中的实际施工人而言，由于《建设工程司法解释（二）》第19条已经提出以建设工程质量合格作为承包人行使建设工程价款优先受偿权的前提条件，仍需对优先受偿权优先权以施工合同有效为基础，以及代位主张优先受偿权的具体条件作出细化规定。具体可以表述为：“实际施工人在总承包人或者转包人不主张或者怠于行使工程价款优先受偿权时，就其承建的工程在发包人欠付工程价款范围内主张优先受偿权，人民法院应予支持。”

（二）代位行使的后果选择

值得注意的是，依照《合同法司法解释（一）》第20条的规定，债权人向次债务人提起的代位权诉讼在经人民法院确认后，将产生直接消灭债权人与债务人之间的债权债务关系的法律效果。司法实践中，实际施工人因工程款纠纷向发包人提起的代位权诉讼，如果得到人民法院的支持，通常也是判令由发包人直接向实际施工人履行支付工程款的义务。

但笔者认为，实际施工人代为主张建设工程价款优先受偿权的，仅能产生权利人已经行使优先

〔47〕参见许明月著：《抵押权制度研究》，法律出版社1998年版，第175页。

〔48〕参见张巍：《建设工程承包人优先受偿权之功能研究》，载《北大法律评论》2005年第7卷第1辑，第255页。

〔49〕参见申卫星：《信心与思路：我国设立优先权制度的立法建议》，《清华大学学报（哲学社会科学版）》2005年第2期，第62页。

〔50〕参见田土城、王康：《论民法典中统一优先权制度的构建》，《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》2016年第6期，第69页。

〔51〕参见孙新强：《破除债权平等原则的两种立法例之辨析——兼论优先权的性质》，《现代法学》2009年第6期，第178页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

受偿权的效果，因行使建设工程价款优先受偿权而取得的财产，应当归属于有效施工合同的承包人。实际施工人因工程建设享有的折价补偿请求权，并不由此直接受偿，仍需依普通债权另行主张。这一规则与《合同法》草案中曾提出的所谓“入库”规则类似。从理论上讲，《合同法》第 73 条的规定中本无从看出对所谓入库规则的规定，但从代位权制度的立法旨意来看，“入库”规则的适用更加符合代位权制度的本质。有观点认为，代位权在法理上属于债的保全，它不是请求权，而是以行使他人权利为内容的管理权。〔52〕债权人行使代位权的目的虽然是为了自己的债权得到清偿，但是代位权的行使和代位权的客体并非同一概念，代位权的行使是债权人以自己的名义，实现对债务人责任财产的保全，对全体债权人的债权提供共同担保的过程，而由此取得的代位权的客体，仍应归属于全体债权人。〔53〕况且，这一规则并非全然依据传统合同法观念中的“入库”规则，以增加债务人的责任财产的方式，提高债权人的债权受到全面清偿的可能性，更大程度上是基于建设工程价款优先受偿权的法定性及其本身所具有的物权属性。由此，《合同法司法解释（一）》关于债权代位制度下的直接清偿规则不应当适用于由实际施工人代位行使的建设工程价款优先受偿权中。

（责任编辑　陈景善）

〔52〕参见史尚宽：《债法总论》，中国政法大学出版社 2000 年版，第 445 页。

〔53〕参见崔建远、韩世远：《合同法中的债权人代位权制度》，载《中国法学》1999 年第 3 期，第 35 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

the jurisdiction of arbitration and the recognition and enforcement of arbitral awards. This paper analyses the legislation and practice of arbitrability of disputes in company law in China, introduces the new progress of German and Russian jurisdictions on this issue in recent years, and puts forward three preliminary suggestions. First, to amend the general provisions of arbitrability in the Arbitration Law to leave enough space for arbitration of disputes in company law; Second, to confirm the arbitrability of some company law disputes by adopting legislation or establishing precedents in view of the particularity of disputes in company law. Third, head arbitration institutions can try to formulate and publish special arbitration rules and model clauses for company law disputes.

Abandon Monopoly Thinking to Eliminate the Barrier of Fair Competition in the Market 63

HUO Yufen/Associate Professor, Institute of Economic Law, Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law; Supervisor of master candidates.

Abstract: In recent years, relevant government departments issued a series of administrative orders and regulations, which made the trading platform of state-owned assets of enterprises become a monopoly trading platform for the disposal and circulation of state-owned assets of enterprises. This violates the core values of the socialist market economy, equality and justice, and also deviates from the ultimate goal of maintaining and increasing the value of state-owned assets. Through a perspective analysis of a series of orders and regulations issued by the relevant government departments, this paper points out that they restrict sufficient fair competition, and further affect the state-owned assets in the process of optimizing the market and activating the stock, which makes it difficult to maximize the market value. The paper also puts forward to abandon the rigid and aging thinking pattern of specifying, managing, constraining and supervising the market by administrative order. It gives full play to the automatic regulation function of the market, and eliminate the barriers that hinder fair competition in the market of state-owned assets trading, so as to create a market environment in which all competitors can participate equally and compete fairly. It also discusses the proper and feasible way for a large number of legally established private intermediary trading institutions in circulation to equally participate in state-owned property rights transactions.

Empirical Study on Priority Right of Compensation of Construction Project Price of Actual Constructors 75

TANG Qian/The Supreme People's Court.

Abstract: Article 286 of the Contract Law establishes the system of priority of compensation for construction project price, which is of great significance to rectify the imbalance between the status of the employer and the contractor and to solve the problem of arrears in construction practice. In the construction contract, illegal subcontracting and borrowing qualifications make the problem that the actual builder is in arrears is more serious and complex. For this reason, some opinions hold that the actual constructor should be given priority to the right of compensation for the construction project price. However, the empirical study shows that, in view of the claim of the priority of compensation for the construction project price of the actual builder, the results of the judgments of the local courts are not uniform and the reasoning is not clear. According to the relevant provisions of the Interpretation of the Supreme People's Court on the Application of Law in the Trial of Disputes over Construction Contracts of Construction Projects (2), which was promulgated recently, the main body of the priority right of compensation for construction project price is limited to the contractor who concludes the construction contract with the employer. Because there is no direct construction contract relationship with the employer, the actual constructor is excluded from the priority right of compensation. Indeed, from the perspective of hermeneutics, the function of the system of priority of compensation for construction project price to balance the relationship between the employer and other creditors of the contractor can not be ignored, and the contractor of invalid construction contract should not enjoy the priority of compensation for construction project price. However, when the general contractor, subcontractor or qualification lender in an effective construction contract is idle in exercising the priority right of compensation for the construction project price, in order to successfully realize the legitimate creditor's rights arising from the construction project, the actual constructor can claim the priority right of compensation for the construction project price by instituting subrogation action.

Qin Dynasty's Death: An Analysis of the Unbearable Responsibility of Legalist Thought 88

JIANG Dengfeng/China University of Political Science and Law.

Abstract: Qin unified China, which lasted for fifteen years. The reason for the death of Qin is often attributed to the thought of the Legalism. In fact, from the perspective of history, there is no direct and inevitable connection between the death of Qin and the Legalism, but for thousands of years, the Legalism has been carrying the black pot

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net